

<60회 민사소송 기출문제 예시답안>

안녕하세요, 한빛 강사진 일동입니다. 올해 2차 시험 보시느라 정말 고생 많으셨습니다. 문제길이도 그렇고 사실관계 파악에 있어서도 크게 어렵다고 느껴질 만한 문제는 없었고, 문제2와 문제4의 지문의 길이가 길어서 긴 지문을 통해서 문제를 푸는 연습이 조금 부족했다면 약간의 답답함은 존재할 수 있었을 것 같습니다. 그리고, 문제2의 설문(2)는, 상고심이 환송해야 하는지 혹은 자판할 수 있는지 관련하여 사실관계가 명확하지 않아 답안이 충분히 갈릴 수 있는 부분으로 보였습니다.

이번 시험에서도 중요했던 것은, 기출강의나 GS 때 항상 말씀드리듯, 문제 사실관계가 있다 하여 무조건 관련 논점을 다 적고 보는 것이 아닌, 설문에서 물어보는 것이 무엇인지를 정확히 판단해서 거기에 맞는 물어보는 것에 충실한 논점만을 작성해야 한다는 것입니다. 문제 사실관계에 특정 논점이 보인다고 하여 단순히 적었을 때는 배점이 부여되지 않습니다. 그 구체적 의미는 이하 답안을 보면서 확인해보시기 바랍니다. 각 설문에 맞는 논점을 쓰는 것, 즉 위치설정이 시험에서는 가장 중요한 부분 중 하나입니다.

이하 예시답안의 목차를 첨부합니다.

모두 10월에 좋은 결과 있으시길 바랍니다.

<문제 - 1>

I. 설문(1) [형.심.당]

1. 문제의 소재
2. 참가승계의 의의, 취지
3. 전주가 승계효력 다투지 않으나 탈퇴, 취하 하지 않는 경우 - 학판검 [형]
4. 필수적 공동소송의 심판방법 - 연합관계

(1) 판결 및 상소의 통일

(2) 사안

일부판결 불허 -> 판단누락에 준하는 위법이 있는 전부판결 -> 상소로 구제

5. 설문해결

불복대상이 없다고 본 항소심법원 판단은 위법함.

cf. 필수적 공동소송의 목차틀 [형.심.당]을 현출하면 빠르게 풀 수 있는 문제

cf. 문제에서 물어본 것은 공동소송의 심판방법에 근거하여 항소심법원의 판단을 물은 문제로, 참가승계를 했다고 문제에서 주어졌다 하여 참가승계 요건을 포섭하는 것은 배점에 유리하지 않음. (즉 참가승계가 되었음을 전제로 그 이후를 물어보는 것이 지 참가승계 적법여부를 논할 필요는 X)

II. 설문(2)

1. 문제의 소재
2. 서증제출의 원칙 - 원본제출주의(제355①)

(1) 내용

(2) 예외

3. 사본 제출이 가능한 경우

(1) 원본에 같음하여 제출하는 경우

(2) 원본으로 제출하는 경우

(3) 사안

1) 원본에 같음하여 제출하는 경우 -> 상대방의 이의가 없이 부지로 다투었는 바 원본의 존재와 진정성립 인정 불가

2) 원본으로 제출하는 경우 -> 증거에 의해 사본과 같은 원본이 존재하고 원본의 진정성립이 인정되는 사정이 없는 바 인정 불가

3) 判例는 문서 진정성립의 경우 변론전체취지로 인정 가능하다고 보나, 이는 원본을 제출할 때의 경우로, 사본을 제출한 경우에는 적용되지 않는다.

4. 설문해결

따라서 사본만을 제출했음에도 변론전체취지에 따라 원본의 존재와 진정성립을 인정한 법원의 조치는 위법하다.

cf. “변론전체취지만으로 사실인정을 할 수 있는지 - 학판검”은 주논점X -> 이는 주요사실을 변론전체취지로 인정할 수 있는지 논할 때 쓰는 것이지 지금 문제는 사본 제출과 원본 간의 관계를 물어보는 문제 (즉 보조사실 관련)

-> 물론, 주요사실에 대해선 인정 안되나, 문서의 진정성립을 변론전체취지로 인정한 케이스(원본 제출의 경우)가 있다는 내용을 쓰기 위한 선결로 학판검을 쓸 수도 있겠으나 이는 우선 위 예시답안 목차들이 모두 현출되어있는 것이 기본 전제가 되어야 함.

cf. 고득점의 방법은 위 목차 3-(3)-3)과 같이, 원본의 경우는 진정성립 인정한 케이스가 있으나 사본의 경우 적용되지 않는다는, 이와 같이 각 개념별로 위치설정을 명확히 하고 있음을 추가로 보여주는 것임

III. 설문(3)

1. 문제의 소재
2. 중복소제기의 의의, 취지
3. 중복소제기 요건

당사자 동일하고 전소 계속 중 후소제기한 것이나, 소송물 동일 여부 문제

4. 소송물 동일여부 [대.사.부.말.소]

2010다80503 判例

5. 설문해결

중복소제기는 소극적 소송요건 -> 흠결시 각하

cf. 단순한 공격방어방법의 변경에 불과한 경우 [대.사.부.말.소] 케이스 중 하나

cf. 4번 목차 서술시 사해행위취소 논점에서 많이 쓰이는 키워드인 “고유의 권리”를 현출하면 안됨 -> 해당 키워드는 채권자가 서로 다른 경우에 서술함,

<문제 - 2>

I. 설문(1)

1. 문제의 소재
2. 대표권의 취급
 - (1) 제64조
 - (2) 흠결시 취급

소송요건으로서 직권조사사항이고 흠결시 소각하한다. 직권조사사항은 **의문이 있을 경우** 이를 직권으로 조사할 **의무**가 있다. 사안에서 항소심법원은 대표권이 있는지 의심할 만한 사정이 있으므로 이를 조사해야 한다.

3. 지적의무 행사 요부
 - (1) 의의,취지(제136조4항)
 - (2) 요건

(3) 행사방식

(4) 관련 判例 [적.기.부.취.이.대]

(5) 사안

대표권 흠결은 i)甲,乙이 간과했음이 분명한 ii)법률상 사항으로 iii)이로 인해 소각하되었는 바 재판결과에 영향을 미치므로 iv)법원은 甲에게 지적의무를 행사했어야 한다.

4. 설문해결

따라서 법원이 지적의무 행사도 없이 대표권 흠결로 보아 바로 소를 각하한 것은 위법하다.

cf. 지적의무는 당사자 불측의 판결을 통한 피해를 위한 구제수단으로 간과한 것이 분명한 법률적 사항을 통해서 당사자 입장에서 불측의 판결이 내려졌는가를 판단의 일응 기준이 될 수 있습니다.

cf. 문제 사실관계에서 “B의 대표자 지위에 관하여 **다툼 적은 없음**”에도 (바로) 소각하 판결한 것 -> 해당 키워드를 보고 법원의 조치인 [석.지.보]를 떠올려야 함 -> 그 중에서도 소송요건에 대한 것인 바 지적의무 행사 要

cf. “대표권이 있는지 **의심**할 만한 사정이 있음에도” -> “소송요건의 조사” 논점 떠올릴 수 있어야 함

cf. 위와 같은 논점추출 키워드를 사례집을 통해 파악하여 기본서에 단권화해두는 것이 중요함 (특히 **지적의무, 석명권의 논점은 키워드 준비없이 놓치기 쉬움**)

cf. 지적의무 요건 이하 일반론 장황하게 서술 No -> 설문해결 무관, 위 예시답안과 같이 사안포섭시 지적의무의 요건을 정확히 포섭하는 것이 득점Point

II. 설문(2)

1. 문제의 소재

2. 소송행위의 추인

(1) 의의, 취지

(2) 방법 및 시기

명시, 묵시 가능 / **상고심에서도 가능**(判例)

(3) 추인의 효력 - 소급효

(4) 사안

상고심에서 임시총회에 의한 추인이 있었는 바, 항소심의 소각하 판결은 **결과적으로** 위법한 판단이 되었다. (참고: 추인 전까지는 항소심 판단은 적법했음)

3. 상고심 판단

(1) 원칙 - 파기 환송

(2) 예외 - 파기 재판

(3) 사안

항소심 판단은 위법하므로 상고심은 원판결을 파기하고, 확정된 사실관계를 바탕으로

재판하기 충분하다는 사정이 없는 바 재판하지 않고 환송해야 한다.

4. 설문의 해결

cf. 소송요건 판단시기 논점X -> 추인에 의해 소급효가 이뤄졌는 바, 항소심 사실심 변종시 기준으로 적법한 판단이 된 것.

cf. 문제 사실관계가 명확하지 않으나, 항소심이 본안에 관해 판단한 사정이 있으니 이를 들어 상고심이 제437조1호의 자판사유라 판단해 재판(하여 항소기각)할 수도 있다고 봄. 다만 이 경우 소각하에 대해 원고만 불복했음에도 청구기각판결이 확정되는 불리한 판결이 생길 수 있으므로 결국 상고기각함(2018다227087 判例)

cf. 다만 문제사실관계에 자판사유임이 명확하지도 않고, 행여 자판사유라 하더라도 위 판례를 안다는 가정 하에 원판결 파기하지 않고 상고기각으로 결론 내리기는 쉽지 않을 것으로 보임 --> 시험장에선 자판사유가 아님을 들어 파기 환송으로 결론 내릴 듯 합니다.

<문제 - 3>

I. 설문(1)

1. 문제의 소재

2. 불복하지 않은 부분 이심 여부 - O

(1) 상소불가분원칙

(2) 사안

상불원에 의해 1억 전부 이심

3. 불복하지 않은 부분 심판대상 여부 - O

(1) 불변금의 의의, 취지(제415조 본문)

(2) 불이익변경금지원칙의 예외(제415조 단서)

(3) 사안

원고만 불복하였으나 피고가 항소심에서 상계주장을 하였는 바, 불이익변경금지원칙이 적용되지 않고 법원은 상계로 주장된 6천만원 전부 판단하여 원고의 청구 4천 인 용 가능

4. 설문해결

甲청구 4천만원을 인용한 항소심 법원의 판단은 타당함.

cf. 불변금의 예외 사안이므로 굳이 불변금 판단기준 서술 불요 (불변금의 판단기준은 “피고의 (1심에서의) 상계항변으로 인해 원고청구기각되고 이에 대해 원고 혹은 피고가 불복한 경우” 논점임) -> 다만 배점이 부족하기에 간단히 불변금 판단기준의 원칙인 ‘주문’ 기준으로 판단한다는 내용 추가 서술은 가능할 것. 쓰지 않아도 무방.

cf. 해당 불이익변경금지원칙의 예외는 동일한 논점으로 8점으로 기출된 적 있음. 부담감 없이 담백하게 작성했으면 걱정않아도 될 것.

II. 설문(2)

1. 문제의 소재 - 기일지정신청의 의의(규칙 제67조)

2. 민법상 규정을 유추하여 취소가부 - 학판검

3. 소송행위의 철회

(1) 소송행위의 철회의 원칙과 제한

(2) 제한의 예외 - 제451조1항5호 재심사유 유추

(3) 유죄확정판결 필요여부

(4) 검토

(5) 관련판례 - 착오

(6) 사안

i)유죄확정판결X ii)의사없이 외형만 존재하는 경우도X -> 철회 불가

4. 설문해결

결국 민법 유추 취소나 소송행위 철회(민소법 유추) 모두 안되므로 소송종료선언.

cf. 위 사안은 타인의 형사상 처벌받을 행위로 이루어진 케이스도 아니고, 착오는 특히나 소송행위 철회 가능한 요건 i),ii) 중 ii)요건이 함결되는 케이스이기에 배점 조절을 위해 3.(1)(3)(4) 목차 생략 가능. -> 다만 위 소송행위 의사표시 하자과 철회 논점은 정형적인 목차가 있기에 기계적인 현출을 위해 구분없이 모두 써놓은 것.

III. 설문(3)

1. 문제의 소재

2. 재판상 자백의 의의(제288조)

3. 요건[변.일.불.주.사]

나머지 요건([변.일.불]) 간단히 포섭 후, 소유권에 기한 등기말소청구소송에 있어 甲의 소유권은 선결적 법률관계인 바 이렇게 사실이 아닌 권리, 법률관계에 대해서도 자백이 성립하는지 문제된다.

4. 선결적 법률관계에 대한 자백 가부 - 학판검

-> **소유권을 이루는 사실(ex. 매매, 증여 등)에 대한 자백 성립**

5. 자백의 효력

6. 설문해결

따라서 법원은 甲의 소유사실을 인정한다고 판단해야 함.

cf. 자백의 요건 불충족시 효력을 쓸 필요 없으나, 요건을 충족하면 반드시 효력까지 써줘야 법원이 어떤 판단이 가능한지 서술 가능함.

<문제 -4>

I. 설문(1)

1. 문제의 소재
2. 추후보완의 의의, 취지(제173조)
3. 추후보완의 요건
 - (1) 불변기간의 도과 -> 항소기간은 불변기간
 - (2) 책임질 수 없는 사유 - 공시송달의 경우
 - 1) 원칙 - **심급** 처음부터 공시송달된 경우
 - 2) 예외 - 소송 진행 도중 공시송달된 경우
 - 3) 관련 判例 (2015다213322)

(3) 사안 : key -> 당사자의 “소송진행상황 조사의무” 여부

당사자가 조정불성립시 소송절차로 이행됨을 알 수 없었을 것이므로 **소송진행상황 조사의무**가 없다. 따라서 추후보완사유 인정.

4. 설문해결

추후보완항소가 허용되지 않는다고 본 항소심법원의 판단은 부당함.

cf. 날짜가 없으므로 추완 절차 내용 쓸 필요X -> 문4 설문(2)에 배치해야 위치설정 올바름.

cf. 기타 다른 주소변경신고 관련된 추후보완항소 어떤 판례를 쓰더라도 사안과 무관함 (판례 취지를 이해 못한 것) -> 배점X

cf. 추완항소의 개별적인 추완사유 인정여부 판례를 암기할 필요는 없으나 그 결론을 정확히 판단할 줄 아는 것은 중요함을 매번 강조함. 위 목차에도 3-(2)-3)의 관련 판례는 답안지에 문구까지 정확히 현출하지 않았어도 무방. 다만, 1)과 2)의 기본 판례를 적어줌으로써 “소송진행상황 조사의무”를 기준으로 판단해야 한다는 판단기준을 명확히 보여준 후, 이에 따라 사안포섭시 위 키워드를 넣어 ‘조정불성립으로 소송으로 넘어가는 것은 알지 못했을 것인바 조사의무 없다’라는 결론을 틀리지 않게 내리는 것은 기본서를 전부 ‘이해’하며 읽었다면 내릴 수 있는 결론이어야 함.

II. 설문(2)

1. 문제의 소재
2. 추후보완 요건 만족 여부 - O
 - (1) 관련 判例 - 교도소 수감(**피고측, 2019다220618**)
 - (2) 사안 - 책임질 수 없는 사유
3. 추후보완 절차 만족 여부 - O
 - (1) 원칙
 - (2) 공시송달 判例 서술
 - (3) 사안

2주 이내이므로 만족.

4. 설문해결

추완요건 만족하였고 2주 내로 추완항소 제기하였는 바 적법함. 따라서 항소심법원 판단은 위법함.

cf. 위 판례 취지를 잘 녹여야 함. 단순히 교도소 수감인 사유만으로 책임질 수 없는 사유 인정한 것이 아님(66마958 판례와 비교, 원고측 교도소 수감 Case)

cf. 이 또한 위 판례를 녹이지 못했더라도 왜 책임질 수 없는 사유에 해당하는지, 즉 왜 당사자가 소송진행상황을 몰랐을 지 “소송진행상황 조사 의무”를 키워드로 하여 녹여 써서 올바른 결론을 내리면 고득점 가능.

cf. 민사소송법에서 최근 1~2년 내 판시된 최신판례를 출제한 경우는 적어도 45회 이후로는 없었는데, 이번 2019다220618 판례는 2022.1.13. 선고된 사안으로 작년 선고된 판례라는 점에서 최근 1~2년 내 판시된 사안도 나올 수 있다는 것을 확인했다는 점에서 유의미함. 그러나 시험 당해년도 선고 판례는 여전히 나오지 않았다는 점에서 그 해 최신판례의 중요성은 역시나 크지 않다는 것을 알 수 있음.

-고생하셨습니다-